



はじめに

本稿では、民法および民法学がどのようなものであるのか、それらの一端について、「人」という切り口からの説明が行われる。『『事実の（de facto）世界』と区別して、別個に『法と権利の（de jure）世界』を構成する技術は、『西洋』に始まる制度である。そこでは、事実の世界でおきる人間の接触交流の要点に、法と権利の世界の効果が対応する。』¹⁾といわれる。この世界観に照らせば、「人」は、「事実の世界」に存在する生身の人間や企業などとは異なり、「法（と権利）の世界」に属する「概念」である。民法学は、この区別を活用して物事を考える。はじめに、民法とは何かについて、ごくおおまかに情報を共有しておきたい。

1. 形式

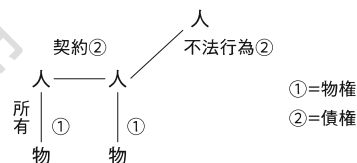
まず、形式的にみれば、民法は、「権利」の変動（発生・変更・消滅）に関するルールを集積である。ここでいう「権利」とは、物の所有権（「物権」の例）、債務者に対して金を払えと請求する権利（「債権」の例）などである。そしてルールとは、斯々然々の条件が揃えば「要件」、権利について斯々然々の変動（発生・変

更・消滅）が生じる「効果」という約束事である。ルールは、民法典（民法という名前の付いた法律）に明記されていることもあるが、重要なルールであっても当然の前提だということで書かれていないことも珍しくない（そうした事情もあり、条文だけでなく、教科書を読む必要がある）。民法の世界では、実社会の紛争を、民法上の権利の有無という形に翻訳して把握する。たとえば、実際には、さまざまな感情がうごめくはずのもめごとが、民法の世界では、民法709条が定める、不法行為による損害賠償請求権（債権）が生じるための要件が充足されたか否かという形を纏ったりする。

2. 実質

つぎに、実質的にみれば、民法は、商品交換法の基本構造を示すものとされてきた。

図2)



基本構造を形成するのは、(a)法主体である「人」、(b)「人」が物を直接に支配する「所有」、(c)「人」が他の「人」との間で各自が「所有」する「物」を交換するための「契約」、これら3つの制度である。現代の民法では、人間であればだれでも、民法上の「人」と認められ、物を「所有」し（所有権＝物権）、「契約」（＝両当事者について、それぞれ、相手にその「物」を引き渡すことを請求する権利〔＝債権〕を発生させる要件）によって、「所有」する物を他の「人」と交換することを実現できる（実際には、金銭と商品とを交換する〔所有権移転という権利変動が生じる〕ことが多いだろう）。「人」というのは、ここでは権利や義務の主体となる地位ないし資格のことであるから（権利能力という）、「人」とされた人間が、実際には何も具体的な権利を持たないこともあれば、相続などによってたくさんの権利を持つこともある。「所有」する物が他の「人」に奪われた場合にはこれに対する返還請求権（所有権に基づく返還請求権。

1) 京極純一『日本の政治』（東京大学出版会、1983年）扉。

2) 内田貴『民法Ⅰ総則・物権総論（第4版）』（東京大学出版会、2008年）17頁の図を参考に作成した。

「所有」制度の一内容)が、その物を他の「人」が壊した場合にはこれに対する損害賠償請求権(不法行為によって生じる損害賠償請求権。債権の一例)が、当該物を「所有」する「人」を権利者とする形で、通常は、発生する。

「人」の外延

I でみたとおり、「人」は、権利(裏からいえば義務)の主体を構成する制度として、民法という仕組みの基礎を成している。とはいえ、人間であれば、だれでも民法上の「人」であることに今日異論はないから、「人」に関する民法の学びにも、それほど難しいところはなさそうに見える(イヌやサルは人間ではないから、民法上の「人」ではない=権利義務の主体とならないことくらいをたしかめておけばよさそう)。ところが、少し歴史をふりかえると、人間=「人」が決して当たり前でなかったことが知られる。

民法学という観点からは、「人」概念が、その抽象性ゆえに、時につれ、事実の世界に属するさまざまなものを包摂してきたこと、それが、平等取扱いという価値と関係しているようであることに注意が必要である。

1. 人間

一方で、人間であっても「人」ではない者があった。伝統的には、人間社会に身分というものがあつた。身分に応じて法的地位が異なっており、中世ヨーロッパで今日という民法の世界に登場するのは、基本的に家長であつた(他にも家族構成員はいたはずなのに)³⁾。そして、それほど遠くない過去まで、奴隷は、人間であるにもかかわらず「人」でないとされていた。伝統的な法的二分法によれば、「人」でなければ「物」とされ、権利の主体ではなく、客体となる⁴⁾。日本では、現行民法制定時(明治29〔1896〕年)、その冒頭に、「私権ノ享有ハ出生ニ始マル」との規定が置かれたが(現在の民法3条1項に相当。同様の規定を持つ民法典は珍しくない)、これは、「単に権利能力の始期だけを規定したのではなく、すべての人は生まれながら

にして権利能力を取得する、という近代法の大原則を民法の劈頭に掲げたものと、解釈されているのである⁵⁾。

また、歴史的に、法の世界で男性中心社会が想定されてきた影響は民法典制定後も残り(民法原始規定14条「妻カ左ニ掲ケタル行為ヲ為スニハ夫ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス〔以下略〕」〔いわゆる「妻の無能力」に関する規定〕、同789条「妻ハ夫ト同居スル義務ヲ負フ／夫ハ妻ヲシテ同居ヲ為サシムルコトヲ要ス」〔妻だけが同居義務を負う〕など)、民法上、同じく「人」であるはずの男女の処遇が法形式上基本的に平等化されるには、個人の尊厳と両性の本質的平等(現在の民法2条)を謳う昭和22(1947)年法律第222号による民法改正を待たなければならなかったことも、忘れてはならない。

2. 団体

他方で、人間でなくとも「人」とされるものがある。民法は、法人というものを認めている(民法第1編総則第3章法人)。講学上、人間は、法人と区別されるために、(人ではなく)自然人と呼ばれ、自然人と法人とが、同格で「人」の下位概念になると整理されてきた。法人とは、形式的に言えば、自然人以外に法主体性が認められたものである。たとえば、特定非営利活動促進法(平成10〔1998〕年法律第7号)に基づいて設立されたNPO法人や、会社法(平成17〔2005〕年法律第86号)に基づいて設立された各種の会社は、法人である。民法33条1項は、「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。」と定める。この規定につづいて、制定当時の民法には、公益社団法人・公益財団法人に関する一群の規律が設けられていたが、これらの規定の大半(38条から84条まで)は、いわゆる公益法人制度改革による法人法制の見直しに伴い、民法から削除された(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〔平成18(2006)年法律第50号〕38条)。そして、非営利(コ公益)の社団法人・財団法人に関する基本ルールが、新たに一般社団法人及び一般

3) 村上淳一『近代法の形成』(岩波書店、1979年)86頁。

4) 原田慶吉『ローマ法〔改訂〕』(有斐閣、1955年)

49頁。

5) 我妻栄『新訂民法総則』(岩波書店、1965年)45頁。

財団法人に関する法律（平成18〔2006〕年法律第48号）に置かれることになった。その結果、現在の民法の法人の章には、法人が法律の規定によってのみ成立すること（33条1項）、法人に認められる能力の範囲（34条）、法人は登記されるべきこと（36条）程度の定めしか残っていない。とはいえ、民法にこれらの規定が残されたことによって、いまなお、法人も民法上の「人」であることが、法体系の基層レベルで確認されているものと考えられる。今日では、「人」概念が、団体以外のもの——動物、自然環境、AIなど——も包摂しうかが検討されるようになってきている⁶⁾ことも付記しておこう。

歴史をふりかえれば、法人が「人」とされたのは、比較的最近のことである。日本民法学の代表的体系書は、法人の歴史について、以下のように述べる。すなわち、「近代の個人自由主義の最高潮時代における民法は、権利能力を有するものも個人に限り、団体を、最小限度において、例外的に個人になぞらえられるものとした。しかし、第十九世紀から第二十世紀にかけての個人主義経済組織の発達には、おのずから、その社会に、団体の独自の存在を認めねばならないようになり、現代の法律組織においては、団体もまた個人と並んで、権利の主体たりうるもの、すなわち権利能力を有するもの、と考えられるにいたった」⁷⁾。日本の最高裁判所⁸⁾も、会社が、「自然人とひとしく、国家、地方公共団体、地域社会その他」の「構成単位たる社会的実在なのである」と述べ、自然人と法人が対等の立場で社会を構成するものと考えているようである。しかし、これに抗う、個人を基調とする構想も示されている⁹⁾。1804年、世界初の民法典を創り出したフランスは、結社を敵視してきた伝統を有し、その民法典は、いまなお、法人に関するまとまった規定を持たない。今日のフランス民法学は、法人も権利義務の帰属主体であることを認めるが、代表的な教科書は、自然人の法人に対する優位を明言する¹⁰⁾。日本民法における自然人法人等置の背景には、20世紀前半の時代思潮を色濃く反映する我妻栄の素朴な歴史発展図式——個人主義から団体

主義へ——があり、21世紀前半のいま、民法の法人関連規定は空洞化していることを考慮するなら、民法の解釈として、「人」概念の下で、法人を自然人と同格としつづけることでよいかは、検討の余地がありそうである¹¹⁾。

「人」の属性

Ⅱでは、主として「人」概念の外延の拡張——および拡張への反省——をみた。今度は、「人」の性質、それも自然人のそれに照準を合わせてみよう。

民法学は、個別の紛争、個々の利益主張にも注意を払うけれども、それらを、「法の世界」で受け止め、社会構成員全体にかかわる問題として議論しようとする。そのための技術の1つが、法の世界に属する「概念」である。法概念の中身は、人々の意識や社会の変化と緊張関係を持ちつつ、維持され／変化する。

1. 魂

民法における「人」は、肉体を捨象された魂だけの存在のようにみえることがある。すなわち、民法の条文を冒頭から順にながめていくと、第1編総則あたりでは、「人」（自然人）が、意思表示（契約に代表される法律行為の構成要素）によって自らの権利義務を発生・変更・消滅させるものであることは読み取れるけれども、字面からは、その肉体のイメージが湧いてこない（「人」は、法文上、「者」と表記されることも多い）。民法第3編債権第5章不法行為に至ってようやく、「人」が、身体・自由・名誉（710条）、また、生命（711条）を持つ存在であることがわかる。その後、第4編親族（725条以下）にすすめば、婚姻や親子に関する規定が並ぶので、「人」が、生身の人間であることははっきりしてくる。

民法学も、伝統的には、「人」を、肉体を忘れた魂だけの意思表示マシンのようなものとして把握してきたと思われる。だからこそ、民法のイメージがⅠ2の図によって表現されえた

6) 能見善久『法の世界における人と物の区別』（信山社、2022年）57頁。

7) 我妻・前掲注5)46頁。

8) 最大判昭和45・6・24民集24巻6号625頁（八幡製鉄事件）。

9) 樋口陽一『憲法〔第4版〕』（勁草書房、2021年）

181頁。

10) Gérard CORNU, Droit civil, Les personnes, 13^e édition, Montchrestien, 2007, p8.

11) その先にある、「人一般」と「個人」という問題につき、蟻川恒正『『段階』と『型』——樋口陽一における比較憲法学と憲法学の方法』法時95巻2号（2023年）82頁。

のだし、自然人と法人とを「人」概念の下に同列に置くことに抵抗感も生まれにくい¹²⁾¹³⁾。

しかし、一部の民法学説は、肉体あつての人間だという観点等もふまえて、同じ「人」であっても、自然人と法人とは区別して論じられるべきこと、体系的にも、民法総則編で自然人と法人を並置するのではなく、自然人については、「人の法」として、人格権、自然人に関する民法総則の規律さらに婚姻・親子に関する規律などをまとめる（法人法は分離させる）構想を提示する¹⁴⁾¹⁵⁾。

2. 性別

民法における「人」は、男と女から構成されているようにもみえる。すなわち、かつて、男女の別は、自明であると考えられていたのだろう。「人」の同定要素として、氏名・生年月日・住所とともに、男女の別が掲げられることは、近年でも珍しくない¹⁶⁾。「人」の属性として性別が重視されているとすれば、これは、民法が、社会は男と女から成り立っており、その男と女が婚姻をし（あるいはせずに）親子関係を形成してゆくことを、前提にしてきたということにもなりうる。

しかし、今日、男女の別は自明でなく、中間領域が認められることや、領域間の移行がありうること、性的志向や性自認についても、多様なものがあることが、広く知られている。人々の意識の上でも、「人」が、男女のみから構成され、しかもそれぞれ、もっぱら異性愛志向であるという理解がはらむ問題性に対する認識が、深まりつつある¹⁷⁾。民法学は、この課題について、当事者の視点からの利益不利益だけでなく、「人」概念のレベルで受け止め、状況に応じて従前の「人」概念を更新し、それに対応する社会像を検討する必要がある。

この問題の周辺で、「人」概念の更新と新しい社会像の提示の関連性が看取される例として、「人」の嫡出性の有無に関連する動きがあげられよう。民法原始規定の下では、嫡出子・非嫡出子（庶子）の区別は、イエ制度を抱く社会のなかで、家督相続の資格の有無や順位に関係するため、重要な属性であった。しかし、昭和22（1947）年法律第222号による民法改正によってイエ制度も家督相続制度も廃止され、その後、平成25（2013）年法律第94号によって当時の民法900条4号（非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めていた）が削除された現在、嫡出子であるか否かの違いは、その「人」の父との親子関係の判定方法が異なる（嫡出子は嫡出推定制度、非嫡出子は認知制度）程度のものとなった。現代の家族法教科書¹⁸⁾は、逡巡しつつも、嫡出子／非嫡出子の別を「人」の属性から消滅させようとしている。いわく、①「民法が、まず全体を、嫡出とそれ以外という形に分けて規定していることは、『婚姻関係を前提とする親子』、『それ以外』を全体の最も大きな分類としているように見える」。他方で、②「親子法の最も基本的な要素として、母子関係と父子関係を位置付けるという見方もあるだろう。」「婚姻夫婦と子の親子関係を論ずるのではなく、あくまで母と子の関係、父と子の関係を考えることが、親子法の基本となるという理解」、「嫡出子や非嫡出子という子の身分として問題を理解するということに消極的な立場」からは、「一応、②の方向に向かいそうである」と。

同様に、同性カップルの婚姻をめぐる議論¹⁹⁾についても、当事者の利益不利益のみならず、社会の制度という観点が必要であり、さまざまな利害が交錯する後者の領域での議論を求めるための場の1つが、「人」概念、ないしその属性としての男女の別（の維持・修正なり

12) もっとも、平成16（2004）年法律第147号によって自然人（法律上の表記は「個人」）が一定の根保証をする場合にのみ適用される規定（現在の民法465条の2以下）が設けられたことは、自然人と法人の同格的位置づけに関する変化の兆候ととれなくもない。中田裕康『債権総論（第4版）』（岩波書店、2020年）563頁。

13) なお、意識を有しない人間も、一般に「人」にあたると思われる。

14) 広中俊雄『新版民法綱要(1)総論』（創文社、2006年）、大村敦志「広中俊雄の民法体系論——『人の法』構想を中心に」法時87巻9号（2015年）31頁。なお、石川健治「公法における『人』の属性——憲法と『人の法』」公法75号（2013年）47頁。

15) 「人の法」構想を意識した民法の全体構造「図」（大村敦志『新基本民法1総則編（第2版）』（有斐閣、2019年）14頁）は、本文Ⅰ2の図とは少し違う。

16) 最判平成20・3・6民集62巻3号665頁（住基ネット事件）。

17) 水野紀子「生殖補助医療を考える」法教506号（2022年）89頁。

18) 窪田充見『家族法（第4版）』（有斐閣、2019年）163-164頁。

19) 同性カップルの法的処遇に関する研究会「同性カップルの法的処遇——論点整理のために(1)(2)」ジュリ1577号75頁・1578号98頁（2022年）。

放棄なり、代替する何かの創案なり)、また、婚姻の概念(とくに婚姻制度と親子制度の結びつきをどう考えるか²⁰⁾)となるように思われる。



おわりに

学生の立場になって、民法を学び、期末試験や司法試験などを受験することを想像した場合、とりわけ、試験問題として、ツールとしての民法をいわば所与として、事例問題の解決案を考えさせるような出題が予想されるときには、民法のたくさんの基本概念の外延・内包を理解し、できれば、その定義をきっちり暗記しておきたくなる。さもないと、短い試験時間のなかで、民法という道具箱に入っているたくさんの道具のなかから適切なものを拾い出し、それらを利用して問題を解決することが覚束なさそうだから。

ところが、本稿では、「人」概念について、Ⅱ・Ⅲを通じて、それが時間とともに揺れ動く様子を描いた。学生が、ふわふわしたことを勉強するばかりでは、試験での成果を望むことは難しいだろう。にもかかわらず、なぜ、本稿は、「人」概念のゆらぎを注視したのか。

実は、20世紀後半の有力な民法教科書は、基本概念の定義をあえて書かないという戦略を採用していた。あるもの²¹⁾は、「本書では制度や概念につき、民法の規定を離れていきなり定義を書くということを努めて避けた。定義とは、学問のアルファであり、オメガであって、これを欠くのはおよそ概説書としての体をなさない、との批判もあり得よう。しかし、「従来、教師から……制度の定義をいきなり述べられて……わからないままにただ定義を覚えこんだりすることが少なくなかったと思われる。しかし、それでは、通説により体系化された民法を知ることにはなるが、真に民法そのものを学

んだことになるか否か、疑問がある。」とし、別のもの²²⁾は、そのまえがきにおいて、「抽象的な概念規定や要件・効果の羅列を極力避け、具体的な制度のあり方や機能をまず叙述し、定義などは学生自身にあとで自分で構成させるように、努力した。」と宣言していた。著者たちが企図していたのは、固定された民法システムを前提にして、試験問題に対する正解を導き出す能力の涵養——数学の試験問題が解けるようになるための訓練のような教育?——にとどまらず、堅牢な民法システムを柔軟化して、妥当な解決案を創出し、さらには新しいシステムを提示する能力の涵養だったのではないかと思われる。

法の基本的な概念の定義は、厳格なものではあるが、これを揺さぶり、少しずつ姿を変え、いつの間にか平穩裡にシステム全体の姿を変え、ということとは、社会の変化に法システムを対応させるために必要なことであり、また、新しい法システムを提案することによって社会を変化させるためにも必要なことである。この更新作業²³⁾には、制定法・判例・学説の相互作用が必要となることが多い(制定法を操作するだけで市民社会の基本語彙の意味内容を変えることは難しい)。民法教育のなかで、あえて概念の定義が示されなかったり、概念の外延内包に関する見解の対立が紹介されることがあるけれども、その背景には、以上のような事情があると考えられる。

本稿は、「人」を通じた民法入門を試みるとともに、一見無味乾燥にも思える「人」概念をめぐる議論、とくに時間軸による変遷を意識することによって、(定義を暗記して)所与の固定された民法システムのなかで正解を出せるようになること以外にも、民法を学ぶ意義があることを説明したつもりである。

(こがゆ・たろう)

20) 近年の最高裁の婚姻観をうかがわせるものとして、最決平成25・12・10民集67巻9号1847頁の寺田逸郎裁判官補足意見がある。いわく、婚姻とは、「①単なる男女カップルの公認に止まらず、②夫婦間に生まれた子をその嫡出子とする仕組みと強く結び付いている」(①②は引用者)。婚姻に②の要素が含まれるなら、その婚姻概念に同性婚をそのまま包摂することは難しい。沖野真己「同性カップルと婚姻」東京大学法学部「現代と法」委員会編『まだ、法学を知らない君へ』(有斐閣、2022年)29頁の

分析も参照。

21) 星野英一『民法概論Ⅰ(序論・総則)』(良書普及会、1971年)はしがき8-9頁。

22) 鈴木禄弥・民法講義シリーズに共通のまえがきの1項目。引用は、同『物権法講義〔三訂版)』(創文社、1985年)2頁。

23) 大村敦志『新しい日本の民法学へ——学術としての民法Ⅱ』(東京大学出版会、2009年)は、民法学の任務として、基本的な法概念の「更新」に注目する。